

1500043-68.2022.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA
Comarca: Itaporanga
Foro: Foro de Itaporanga
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 30/09/2022

... TJ/SP:

"Apelação - Associação para o tráfico - Recurso defensivo - Absolvição pretendida - Procedência - Ausência de prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas - Recurso provido. (...)Assim, muito embora o conjunto probatório faça clara referência ao envolvimento dos apelantes no cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Centro - CEP 18480-000, Fone: (15) 3565-1224, Itaporanga-SP -
E-mail: itaporanga@tjsp.jus.br

1500043-68.2022.8.26.0622 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500043-68.2022.8.26.0622

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026155/2022 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 22706306 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 2026155 - DEL.POL.ITAPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO SANTOS GASPAR FILHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de SILVIO SANTOS GASPAR FILHO e GUSTAVO HENRIQUE PADILHA ALVES, qualificados nos autos, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos c.c. artigo 40, V, todos da Lei 11.343/2006, e SILVIO como incurso também no artigo 330 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que os acusados, no dia 28/01/2022, por volta das 17h25min, na Rodovia Juventino Patriarca, nº 59, próximo ao trevo de acesso a Santana de Itararé/PR, zona rural, na cidade de Itaporanga/SP, em concurso de agentes, transportavam, para fins de tráfico entre Estados da Federação, 1,289Kg (um quilo duzentos e oitenta e nove gramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida

como "maconha", na forma de 02 (dois) tijolos (Auto de exibição e apreensão de fls. 06, Laudo de Constatação Provisória de fls. 07/08 e Laudo Químico-toxicológico de fls. 142/145), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou Regulamentar.

A denúncia foi recebida em 08/04/2022 (fls. 193/194).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 213/221 e 259).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual se pretende apurar a responsabilidade dos acusados SILVIO SANTOS GASPAR FILHO e GUSTAVO HENRIQUE PADILHA ALVES pelos fatos narrados na denúncia.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da imputação.

No mérito, a pretensão é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de desobediência está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 06 e 14), exames provisório e definitivo de constatação do entorpecente (fls. 07/08 e 142/145, respectivamente), fotografias dos entorpecentes (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 12/13) e especialmente pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre os acusados.

Por outro lado, não há provas suficientes de que os réus tenham se associado para a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Castilho disse que, em patrulhamento, perceberam dois indivíduos em um automóvel, que demonstraram nervosismo. Que os policiais deram sinal para pararem, mas descumpriram e empreenderam fuga, parando cerca de 02 km depois. Que derrubaram dois tabletes aparentando ser maconha. Que o motorista não conseguiu fugir e foi detido. Que o outro ocupante obteve êxito em fugir. Que o réu Silvio disse que deu carona para o corréu até Salto do Itararé, mas não sabia que ele iria comprar drogas. Que deu sinal de parada com a sirene da viatura e tinha acostamento. Que o réu Silvio tentou empreender fuga. Que não reconheceu o réu Gustavo, pois na ocasião não conseguiu visualizar características suas.

A testemunha Elias Benedito de Oliveira disse que trabalhou na investigação para identificar o coautor dos fatos, apontado pelo corréu Silvio como "Toddynho". Que consultou os policiais de Riversul, os quais contribuíram na identificação do vulgo "Toddynho". Que qualificaram "Toddynho" como sendo o réu Gustavo. Que o único "Toddynho" em Riversul é o réu Gustavo.

A testemunha Jair Martins Lara disse que abordaram o réu em Itaporanga e estavam vindo de Salto. Que deram a primeira ordem de parada no trevo, onde havia acostamento. Que o réu parou próximo ao Posto Turco. Que o passageiro saiu correndo e deixou cair dois tabletes de maconha. Que o Silvio não saiu correndo.

A testemunha Maria Raquel de Campos disse que estava de plantão em Taquarituba e tomou os depoimentos do réu Silvio. Que os policiais já haviam sido ouvidos.

Em seu interrogatório, o réu Silvio negou os fatos. Disse que trabalhava como servente de pedreiro. Que o Gustavo pediu para o réu levar ele até Barão de Antonina, mas sem saber por qual motivo. Que Gustavo voltou com algo embaixo da blusa, mas não sabia o que era. Que o Gustavo pagou R\$ 100,00 para o depoente levar ele até Barão de Antonina. Disse que o carro era do próprio Gustavo. Disse que não parou quando houve a determinação policial por não considerar seguro, mas nega que tenha acelerado demasiadamente o carro ou fugido da Polícia.

O réu Gustavo admitiu o delito. Disse que a droga era, de fato, de sua propriedade e que havia contratado Silvio para fazer um "frete" até a cidade de Barão de Antonina, mas sem que ele soubesse a finalidade da viagem. Que quando a Polícia Militar se aproximou, disse a Silvio que estava com a maconha. Que tentaram parar o carro, mas não havia acostamento.

Tráfico de Drogas

Diante da prova produzida, patente a caracterização do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não convencendo a versão dos fatos relatada pelos réus, isoladas nos autos.

O réu SILVIO foi preso em flagrante transportando, no automóvel que conduzia, a massa líquida de 1,289Kg (um quilo, duzentos e oitenta e nove gramas) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida com maconha, consoante laudo pericial de fls. 142/145, para a finalidade de comercialização.

O réu GUSTAVO, por sua vez, foi posteriormente identificado como a pessoa que estava como passageiro no automóvel conduzido pelo corréu, tendo logrado êxito em empreender fuga. Como restou demonstrado, GUSTAVO foi responsável por adquirir a droga, com a finalidade de sua comercialização.

Alega as Defesas que não há provas suficientes para embasar a condenação.

Sem razão, contudo.

Conforme se fundamentou acima, materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, mostrando-se inconsistente a tese de irresponsabilidade dos acusados, sobretudo pela quantidade de drogas apreendida e demais elementos mencionados, incompatíveis com a alegação de uso (art. 28).

Anote-se, ademais, a palavra segura dos policiais a respeito dos fatos, dotada de fé pública e não informada nos autos. Tampouco demonstrada qualquer intenção de perseguição dos acusados, não sendo razoável presumir que os policiais tenham interesse na causa ou tenham forjado o flagrante, plantando expressiva quantidade de drogas, com isso praticando grave crime (CP, art. 339) e se sujeitando ao risco de perderem suas fardas.

Em relação a GUSTAVO, o réu admite que adquiriu o entorpecente e o transportava para o fim de tráfico, o que corrobora todo o conjunto probatório acima relatado. De igual forma, a prova colhida demonstra que o réu SILVIO concorreu para a prática do delito, transportando o entorpecente e tendo conhecimento da intenção do corréu em comercializar a maconha.

Não convence a versão de que não tinha conhecimento da existência da droga.

Primeiro porque não faz sentido a alegação de que prestaria serviço de transporte, sendo que em seu próprio interrogatório admite que o carro era de GUSTAVO, e que estaria dirigindo porque este não era habilitado. Em segundo lugar, caso estivesse de boa fé, não teria empreendido fuga da Polícia quando foi dado o sinal de parada. Ademais, não há provas mínimas de que o réu costumava prestar serviços de transporte, ainda mais se utilizando do carro de seu cliente. Essas circunstâncias demonstram que o entorpecente era direcionado para comercialização e que SILVIO tinha conhecimento desta circunstância.

Em que pese não tenham vendido as drogas, nem sequer inicializado a comercialização, certo é que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é um tipo misto alternativo, ou de conduta variada, o que significa dizer que o tipo penal é composto por mais de um verbo e admite diversas condutas, bastando a prática de qualquer uma delas para a consumação do delito.

Em assim sendo, a lei não faz qualquer distinção entre "expor à venda", "trazer", "ter em depósito" ou "guardar" com o ato de "vender" propriamente dito, sendo suficiente, portanto, a conduta descrita em denúncia para a configuração do delito de tráfico de drogas consumado. Todas as provas apontam que a intenção dos réus era de comercializar aqueles entorpecentes, tendo em vista a forma de acondicionamento, a quantidade, as circunstâncias da prisão em flagrante do corréu, evidenciando o elemento subjetivo do tipo.

Os acusados eram imputáveis na data dos fatos e tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam beneficiá-los.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus cometeram o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Associação para o Tráfico

Em relação à associação para o tráfico, entendo que esse delito exige para sua consumação a estabilidade como um de seus elementos. Com efeito, o que caracteriza o delito é o manifesto propósito de associar-se, circunstância que pode ser deduzida de qualquer prova que a evidencie.

Nas palavras do professor Guilherme de Souza Nucci, para a configuração do delito de associação para o tráfico "demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa e exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2007, pág. 334).

Assim, somente existindo prova de que havia o vínculo associativo, de caráter permanente, é que se deve admitir o crime do artigo 35, da lei 11.343/06. Não é à toa que o verbo "associar" é núcleo do tipo.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do TJ/SP:

"Apelação - Associação para o tráfico - Recurso defensivo - Absolvição pretendida - Procedência - Ausência de prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas - Recurso provido. (...) Assim, muito embora o conjunto probatório faça clara referência ao envolvimento dos apelantes no cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, a verdade é que as circunstâncias do fato versado no presente feito indicam mais um mero concurso de agentes havido entre eles do que uma verdadeira associação, que pressupõe, ainda que em grau mínimo, certa estabilidade, permanência, divisão de tarefas e vínculo hierárquico entre todos os agentes. Ressalte-se que não ficou cabalmente demonstrado o animus associativo necessário para a caracterização da citada infração penal, uma vez que não basta a estabilidade e permanência, mas sim, cumulativamente com a repartição de tarefas e a hierarquia entre os agentes, pressupostos não elucidados no decorrer da persecutio criminis." (TJSP; Apelação nº 0092491-80.2017.8.26.0050; 8ª Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Roberto Porto; julgado em 14 de fevereiro de 2019).

Este também é o entendimento do STJ nos seguintes julgados:

"HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE QUE TERIA HAVIDO ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Diante da expressão "reiteradamente ou não", contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável. 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. As instâncias de origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto que a confirmou, de que a associação dos pacientes teria alguma estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas. 5. Ordem concedida apenas para absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória prolatada na origem" (STJ, HC 137471/MS - HABEAS CORPUS - 2009/0101923-9 - Ministro Jorge Mussi)

"Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes." (STJ HC nº 208.886/SP Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi DJe 01/12/2011).

Não há qualquer elemento que evidencie que os acusados tinham o ânimo de se associar para cometer o crime de tráfico de drogas. Os Policiais Militares inquiridos, inclusive, não trouxeram informações concretas de que os réus se associam para a prática do tráfico de drogas.

A existência de denúncias anônimas de que os réus praticavam o delito de tráfico de drogas de forma associada não é suficiente para fundamentar a condenação. Se a prova produzida em solo policial, em depoimentos formais com pessoas identificadas, não são suficientes para fundamentar a condenação quando esses elementos não confirmados em juízo, conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, com mais razão denúncias anônimas, sem confirmações de sua veracidade, não ter o condão de basear um decreto condenatório.

No mesmo sentido, destaco a lição de Renato Brasileiro:

"Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão 'reiteradamente ou não', a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência ('societas sceleris'), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)." (Legislação Criminal Especial Comentada: volume único; Renato Brasileiro de Lima; 8. Ed. - Salvador: JusPODIVM, 2020; p. 1080) (grifei).

O conjunto probatório, portanto, é frágil e insuficiente para ensejar um decreto condenatório em desfavor dos réus pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas. Assim, ausente prova da estabilidade entre os agentes, não há que se falar na hipótese no crime de associação para o tráfico de droga.

Causa de diminuição do art. 33, §4º, LD

Superada a possibilidade associação para a prática de tráfico de drogas entre os réus, uma vez que não há provas suficientes da existência do crime, passo a analisar se preenchem os requisitos para aplicação da causa de diminuição constante do §4º do artigo 33, Lei de Drogas.

Verifico das certidões de fls. 321/322 e 325 que os réus são primários e possuem bons antecedentes. Igualmente, não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Assim sendo, os réus fazem jus à causa de diminuição constante do §4º do artigo 33, Lei de Drogas.

Tráfico Interestadual

Não há provas suficientes de que os réus tenham praticado tráfico entre Estados da Federação.

Como se verifica, os réus foram abordados já no território da cidade de Itaporanga, vindo do trajeto que leva a Barão de Antonina, não havendo elementos mínimos indicando que tenham ido ao Estado do Paraná adquirir o entorpecente.

O fato de ser prática comum os traficantes adquirirem drogas em Salto do Itararé não se mostra suficiente, para fins de sentença condenatória, para demonstrar que os réus efetivamente transpuseram a divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, não afastando, portanto, o ônus de prova da acusação.

Em assim sendo, mencionada causa de aumento deve ser afastada.

Desobediência

O crime de desobediência também restou suficientemente demonstrado.

Certo é que o conjunto probatório reunido nos presentes autos, em especial as testemunhas ouvidas em Juízo, comprova que o fato narrado na inicial realmente ocorreu e foi praticado pelo réu SILVIO.

Outrossim, a autoria restou bem demonstrada por toda a prova colhida nos autos.

Como se percebe, restou demonstrado que, após a determinação de parada do veículo pelas autoridades policiais, o réu SILVIO desobedeceu a ordem e empreendeu fuga pela via pública, vindo a parar tão somente metros a frente, próximo a um posto de gasolina.

Assim, tenho por coerentes e convergentes os depoimentos prestados em Juízo, que, com riqueza de detalhes, descreveram os fatos e demonstraram de forma segura a desobediência praticada pelo réu.

Concluo, portanto, que os fatos narrados na inicial realmente ocorreram e foram praticados pelo réu e que autos possuem provas mais que suficientes para a prolação de um decreto condenatório.

Dosimetria

Atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

1. RÉU GUSTAVO

Verifico, na primeira fase de dosimetria das penas, que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas são anormais à espécie, tendo sido apreendida a massa líquida de 1,289 kg de maconha, contudo, tal circunstância será considerada na terceira fase de dosimetria; não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do agente; a culpabilidade se mostra inerente ao delito; antecedentes neutros; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais à espécie; e inexistente o comportamento da vítima.

Mantenho a pena mínima legalmente prevista em seu patamar e fixo, portanto, a pena-base em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa, uma vez que o réu possuía 18 anos de idade à época dos fatos (fls. 177 e 338), e da confissão espontânea. Não há agravantes a se considerar. Considerando que as atenuantes não têm o condão de conduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento, conforme fundamentação acima. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário, com bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme supra fundamentado.

Diante da expressiva quantidade de droga apreendida, faço incidir fração intermediária para a minorante ora reconhecida, que é de 1/2.

Nesse sentido é o Tema 712 do STF. Veja-se:

Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (ARE 666334, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 04/04/2014).

Dessa forma, diminuo a pena intermediária em 1/2 e fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 250 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, fixo o aberto como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do comando do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Em que pese a previsão do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, de que o regime inicial para crimes hediondos deve ser o fechado, duas considerações há de se fazer. Em primeiro lugar, conforme decidido pelo STF, o crime de tráfico de drogas "privilegiado" não se equipara a delito hediondo, razão pela qual referido dispositivo não é aplicável ao presente caso. Não obstante, deve-se fazer uma observação sobre a constitucionalidade desse dispositivo, o qual ofende a garantia constitucional de individualização da pena, conforme decidido incidentalmente pelo pleno do STF no HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em 27/06/2012, fundamento que também seria suficiente para afastar a obrigatoriedade, caso se considerasse hediondo o tráfico "privilegiado".

Em razão do montante de pena e de todas as circunstâncias judiciais acima evidenciadas, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44). Substituo a pena por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação e por uma pena pecuniária no valor de um salário mínimo, a benefício de instituições sociais a serem definidas na execução.

Vale ressaltar que a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do §4º do artigo 33, Lei nº 11.343/2006, teve sua execução suspensa em virtude de ter sido declarada inconstitucional pelo STF no HC 97.256/RS, nos termos da Resolução de nº 05/2012 do Senado Federal.

2. RÉU SILVIO

2.1. Tráfico de Drogas

Verifico, na primeira fase de dosimetria das penas, que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas são anormais à espécie, tendo sido apreendida a massa

líquida de 1,289 kg de maconha, contudo, tal circunstância será considerada na terceira fase de dosimetria; não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do agente; a culpabilidade se mostra inerente ao delito; antecedentes neutros; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais à espécie; e inexistente o comportamento da vítima.

Mantenho a pena mínima legalmente prevista em seu patamar e fixo, portanto, a pena-base em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a se considerar.

Na terceira fase, sem causas de aumento, conforme fundamentação acima. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, Lei nº 11.343./06, tendo em vista que o réu é primário, com bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme supra fundamentado.

Diante da expressiva quantidade de droga apreendida, faço incidir fração intermediária para a minorante ora reconhecida, que é de 1/2.

Nesse sentido é o Tema 712 do STF. Veja-se:

Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (ARE 666334, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 04/04/2014).

Dessa forma, diminuo a pena intermediária em 1/2 e fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 250 dias-multa.

2.2. Desobediência

Na primeira fase de dosimetria das penas, vislumbra-se que a culpabilidade é a inerente ao crime praticado; não há antecedentes a se considerar; não há provas a respeito da sua conduta social ou personalidade; os motivos, circunstâncias e as consequências são normais para o cometimento do crime, restando neutro; comportamento da vítima inexistente.

Nessas condições, mantenho a pena base no mínimo legal, fixando-a, deste modo, em 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Inexistindo quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

2.3. Concurso de Crimes

Tratando-se de crimes de espécies distintas e praticados mediante mais de uma conduta, aplicável ao caso o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Ainda que assim não fosse, o cúmulo material se mostra mais benéfico ao réu do que eventual reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva.

2.4. Demais disposições

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, fixo o aberto como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do comando do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Em que pese a previsão do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, de que o regime inicial para crimes hediondos deve ser o fechado, duas considerações há de se fazer. Em primeiro lugar, conforme decidido pelo STF, o crime de tráfico de drogas "privilegiado" não se equipara a delito hediondo, razão pela qual referido dispositivo não é aplicável ao presente caso. Não obstante, deve-se fazer uma observação sobre a constitucionalidade desse dispositivo, o qual ofende a garantia constitucional de individualização da pena, conforme decidido incidentalmente pelo pleno do STF no HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em 27/06/2012, fundamento que também seria suficiente para afastar a obrigatoriedade, caso se considerasse hediondo o tráfico "privilegiado".

Em razão do montante de pena e de todas as circunstâncias judiciais acima evidenciadas, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44). Substituo a pena por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação e por uma pena pecuniária no valor de um salário mínimo, a benefício de instituições sociais a serem definidas na execução.

Vale ressaltar que a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do §4º do artigo 33, Lei nº 11.343/2006, teve sua execução suspensa em virtude de ter sido declarada inconstitucional pelo STF no HC 97.256/RS, nos termos da Resolução de nº 05/2012 do Senado Federal.

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).
Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

(i) declarar GUSTAVO HENRIQUE PADILHA ALVES como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual substituo por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, em favor de instituições a serem definidas em sede de execução, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo unitário. Ainda, ABSOLVO o réu GUSTAVO da imputação prevista no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal;

(ii) declarar SILVIO SANTOS GASPARG FILHO como incurso nas penas do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, condenando-o a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e a pena de 15 (quinze) dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, as quais substituo por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, em favor de instituições a serem definidas em sede de execução, mais 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, fixados no mínimo unitário. Ainda, ABSOLVO o réu SILVIO da imputação prevista no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal, ante a falta de notícias quanto à condição financeira dos réus.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que responde assim ao processo e não houve alteração nas circunstâncias fáticas que justificassem a decretação da prisão preventiva. Mantenho as cautelares diversas da prisão aplicadas anteriormente.

Oportunamente, expeçam-se certidões de honorários aos advogados nomeados pelo convênio OAB-SP/Defensoria Pública.

Por fim, após o trânsito em julgado:

Expeça-se mandado de prisão.

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Itaporanga, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA